

1502934-66.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2313560/2021 - 01º D.P. GUARULHOS, 21450651 - 01º D.P. GUARULHOS, 3953/21/206 - 01º D.P. GUARULHOS, 2313560 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502934-66.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502934-66.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2313560/2021 - 01º D.P. GUARULHOS, 21450651 - 01º D.P. GUARULHOS, 3953/21/206 - 01º D.P. GUARULHOS, 2313560 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Vistos.

Carlos Vinicius Oliveira dos Santos foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 18 de novembro de 2021, por volta das 0h030min, na Rua Maria Antonieta, 43, Morros, nesta cidade de Guarulhos, agindo em concurso caracterizado pela unidade de desígnios com o adolescente Jadyson Adrian Fernandes de Almeida, traziam consigo, para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros, 94 porções de crack, com peso líquido de 17,8 gramas, 412 porções de cocaína, com peso líquido de 262,3 gramas, 20 porções de maconha, com peso líquido de 62 gramas, e 156 porções de lança-perfume, com peso líquido de 1.092 mililitros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (fl. 69) e apresentou defesa preliminar (fls. 73/75).

A denúncia foi recebida em 07 de março de 2022 (fls. 76/78).

Não havendo elementos que permitissem absolver sumariamente o réu, iniciou-se a instrução probatória. Em audiência judicial foram ouvidas duas testemunhas, sendo o réu interrogado ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa requereu: a) nulidade do processo desde o início, em razão da ilegalidade das diligências realizadas pelos guardas; b) nulidade do processo desde o início, em razão da ilegalidade da abordagem e da busca pessoal, pois os guardas não especificaram no que consistiu a "atitude suspeita"; c) absolvição por falta de provas; d) desclassificação para o art. 28; e) pena-base no mínimo legal; f) atenuante da confissão informal, para compensá-la com a reincidência; g) afastamento da causa de aumento, pois não configurada; h) regime diverso do fechado; i) recurso em liberdade; j) justiça gratuita.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Na fase administrativa da persecução penal foram ouvidas três testemunhas.

Robson Petrone, guarda civil municipal, afirmou que realizavam patrulhamento preventivo e, ao adentrarem na Rua Maria Antonieta, altura do nº 43, local conhecido como ponto de tráfico de drogas, uma entrada da Comunidade da Olaria, visualizaram dois indivíduos. Ao verem a equipe, Carlos largou uma sacola e ambos correram em direção a uma viela, mas foram alcançados. Jadyson, menor de idade, arremessou durante a corrida uma pochete por cima de um portão de madeira, mas foram detidos cerca de 50 metros à frente. Na sacola largada por Carlos localizaram 50 porções de substância aparentando ser crack, 150 frascos de substância aparentando ser lança-perfume e 300 microtubos de substância aparentando ser cocaína. Na pochete largada por Jadyson localizaram 44 porções de substância aparentando ser crack, 6 frascos de substância aparentando ser lança-perfume, 112 microtubos de substância aparentando ser cocaína e 20 porções de substância aparentando ser maconha, além de R\$ 149,80. Em revista pessoal, nada encontraram. Nenhum deles estava portando documentos. Indagados, ambos admitiram o tráfico e que o dinheiro que estava na pochete arremessada por Jadyson era produto do crime. Jadyson afirmou que junto com Carlos ganhavam R\$ 200,00 por noite que vendiam drogas (fl. 08).

O guarda civil Reginaldo Cavalcanti da Silva apresentou relato idêntico ao de seu colega (fl. 09).

Jadyson afirmou que estava no local vendendo drogas na Olaria. Fez isso algumas vezes e que ganha em média R\$ 200,00 por noite. Vende maconha, pó e pedra por R\$ 5,00 e R\$ 10,00. Conhece Carlos como "Vinicius" da favela. "Vinicius" foi apenas comprar drogas dele. Antes da chegada da polícia, "Vinicius" comprou com o declarante um pó de R\$ 5,00. As drogas que vendia estavam em uma bolsinha na sua mão. Correu quando a polícia chegou e jogou a bolsinha em cima de um telhado de um barraco. Não foi pego com ele a sacola com drogas, mas sabe que tinha drogas em uma sacola de onde pega para reabastecer a sua bolsa. Quem abastece as drogas ali são uns "meninos" (fl. 16).

Perante o Delegado de Polícia, o réu disse que não vendia drogas no local e quem vendia era "Adria", o adolescente que foi preso. Conhece "Adria" porque vivem na mesma comunidade. Foi abordado com um maço de cigarro e com sua máscara (fl. 19). Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu.

Reginaldo disse que efetuavam patrulha ostensiva pelo local dos fatos, já conhecido com ponto de venda de entorpecentes, quando qual viu o réu e um adolescente, que correram assim que perceberam a sua presença. O réu largou uma sacola na via. No interior dessa sacola foram encontradas drogas.

Robson afirmou que estavam em patrulhamento de rotina na região do Cocaia. Avistou dois indivíduos, o réu e um adolescente, na entrada da comunidade. Eles correram assim que viram a viatura. O réu estava com uma sacola nas mãos. O adolescente dispensou uma pochete na fuga. No interior da sacola e da pochete foram encontradas drogas. O réu e o adolescente confessaram a traficância.

Carlos negou a prática do crime. Disse que é usuário e estava no local para comprar

drogas. Quando chegou para compra drogas do adolescente, foi surpreendido por policiais, que disseram que iriam atirar. Assustado, correu. O adolescente jogou as drogas para dentro de uma casa. Em seu poder foi encontrado apenas um maço de cigarro e uma porção de cocaína. No momento da abordagem, sofreu agressão dos agentes públicos, pois foi prensado na parede.

Essas são as provas produzidas.

Inicialmente, importante consignar que, no entendimento deste magistrado, a prova produzida nestes autos é ilícita. Com efeito, as guardas municipais têm por finalidade a proteção de bens, serviços e instalações do Município. Não lhes cabem as atribuições de polícia ostensiva e preservação da ordem pública (incumbências da Polícia Militar), tampouco as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais (incumbências da Polícia Civil). É o que dispõe o art. 144, §§ 4º, 5º e 8º da Constituição Federal:

“Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: (...)

§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais (...)

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública (...)

§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.”

Na espécie, verifica-se que o réu na via pública com um adolescente. Guardas civis realizavam ronda quando avistaram os dois e, suspeitando do comportamento deles, decidiram abordá-los, sendo então encontradas as drogas apreendidas.

Os guardas municipais agiram como se policiais militares fossem, excedendo de forma manifesta suas atribuições constitucionais. Não há como autorizar que guardas municipais, fazendo as vezes de policiais militares, realizem patrulhamentos preventivos e a abordagem de pessoas suspeitas.

De se registrar que, como agentes públicos, os integrantes das guardas municipais têm o dever de prender em flagrante qualquer pessoa que esteja cometendo uma infração penal. A toda evidência, seria absurdo impedir que atuassem e obrigar que se permanecessem inertes diante de um crime em andamento. O que não se pode admitir, em hipótese alguma, é que não visualizando situação de flagrância, mas simplesmente suspeitando da ocorrência de um crime, os agentes municipais realizem diligências investigativas visando à confirmação da suspeita.

No julgamento da apelação nº 1501456-29.2018.26.0567, o Desembargador Sérgio Mazina Martins se debruçou sobre a questão, consignando em seu voto:

“Ora, veja-se então que os guardas civis executaram, desde quando avistaram o acusado – tendo inclusive relatado que “quando este teria demonstrado certo nervosismo. Ao estranharem a situação, tentaram se aproximar do réu, que saiu correndo... ” – autêntica atividade policial de busca e apreensão de mochila supostamente pertencente a Murilo, ou seja, inequívoca investigação de notícia de fato criminoso. Não estavam visualizando, naquele momento, nenhuma situação imediata de flagrância, senão, munidos de uma simples desconfiança acerca do “nervosismo” aparente do acusado passaram pretensiosamente a investigá-la como se policiais fossem. No caso, obviamente, haveriam de ter nada mais que repassado tais informações à Polícia Militar ou à Polícia Civil de Sorocaba – serviços públicos que sabidamente existem naquela cidade, também certamente integrados por agentes policiais da maior competência e gabarito técnico, além do que sob controle e acompanhamento institucional adequado – para que elas, se o caso, encaminhassem as investigações devidas.

Ocorre que guardas civis não são – porque não devem mesmo ser – policiais. Nossa ordem constitucional e legal é claríssima nesse sentido ao dispor que compete às policiais civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, o exercício da atividade de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, assim como compete às polícias militares a atividade de polícia ostensiva e a preservação da ordem pública (Constituição Federal, artigo 144, parágrafos 4º e 5º). Nesse

sentido, prossegue o constituinte, às guardas municipais, constituídas pelos Municípios, estão nada mais que simplesmente destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações (Constituição Federal, artigo 144, parágrafo 8º) (...)

Assim, se um guarda municipal porventura intuitivamente desconfiasse que um indivíduo estivesse transportando drogas, se esse guarda municipal fosse devidamente treinado, seu procedimento não haveria de ser outro: deveria de imediato comunicar essa notícia à autoridade policial – ou, eventualmente, à Polícia Militar – para que estas, se entendessem ser o caso, procedessem à devida investigação.

(...)

O tema, aqui, não é se o crime existia ou não. Muito menos se era permanente ou não. O tema, no caso, é como esse crime veio à luz. Como ele se tornou público e veio dar nas páginas do processo. O que grita nos autos, portanto, é a ilicitude da prova que o trouxe para nossas mãos” (TJSP; Apelação Criminal 1501456-29.2018.8.26.0567; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/09/2019; Data de Registro: 19/09/2019)

A questão também foi analisada com profundidade pelo Desembargador Péricles Piza na apelação criminal nº 1500329-51.2018.8.26.0601. Colhe-se do voto:

“Qualquer do povo pode, de fato, dar voz de prisão a pessoas que estejam a cometer crimes em sua frente. É vedado, no entanto, que os cidadãos investiguem os indivíduos com quem partilham da vida em sociedade, bem como lhes é proibido realizar diligências com o fim de verificar o cometimento de ilícitos criminais. Justamente com o objetivo de retirar dos indivíduos o poder de investigar e punir delitos, impedindo assim que o Direito Penal sucumbisse à mera vingança privada, delegou-se o poder de punir ao Estado. (...)

De tal sorte, a diligência realizada pelos Guardas Civis Municipais, uma vez que invade atribuição constitucionalmente delegada a outros órgãos de segurança pública, representa ampliação indevida de sua esfera de atuação. Tal constitui grave ofensa à regra constitucional, uma vez que, como agente administrativo, regido pela legalidade estrita, falece à Guarda Civil Municipal autorização para investigar possíveis ilícitos penais.” (TJSP; Apelação Criminal 0007763-32.2008.8.26.0597; Relator (a): Péricles Piza; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sertãozinho - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/12/2019; Data de Registro: 03/12/2019)

Nada obstante, a Corte de Justiça local, de forma quase unânime, não vê ilegalidade em abordagens como a realizada no presente caso.

O Superior Tribunal de Justiça também tem decidido que “a busca e apreensão de drogas efetuada por guardas municipais não padece da eiva suscitada, embora a Guarda Municipal não possua a atribuição de polícia ostensiva, mas apenas aquelas previstas no art. 144, § 8º. da Constituição da República, sendo o delito de natureza permanente, pode ela efetuar a prisão em flagrante e a apreensão de objetos do crime que se encontrem na posse do agente infrator” (AgRg no AREsp 1565524/MS, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 05/12/2019, DJe 12/12/2019).

Diante disto, a fim de prestigiar a segurança jurídica, curvo-me a este entendimento e deixo de reconhecer a ilicitude da prova.

Também não há que se falar em ilicitude da prova por falta de motivação para a busca pessoal. Isso porque, durante a madrugada, o réu estava parado em um ponto de venda de drogas com uma sacola nas mãos, tendo ainda corrido ao ver os guardas municipais. Diante deste cenário fático, havia fundada suspeita de que ele levava consigo drogas destinadas ao tráfico. Logo, foi legítima a atuação dos agentes públicos.

Resolvida essas questões preliminares, passo ao mérito.

Não obstante a manifestação da combativa defesa, a pretensão acusatória é procedente.

A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 03/07), laudo de constatação prévia (fls.

13/15) e laudos de exame químico-toxicológico (fls. 48/53), os quais constatarem no material apreendido a presença de cocaína, tetrahydrocannabinol e tricloroetileno, substâncias previstas na Portaria SVS/MS nº 344/98.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

Os guardas civis ouvidos narraram com detalhes as circunstâncias da detenção do réu e encontro das drogas. Relataram que faziam patrulhamento pelo local dos fatos quando avistaram dois indivíduos, os quais, após perceberem a presença deles, dispensaram uma sacola e uma pochete e empreenderam fuga a pé. Detidos e recuperados os objetos por eles dispensados, constatarem em seu interior porções de drogas e dinheiro em espécie.

Os agentes públicos apresentaram relatos unânimes, não havendo qualquer contradição ou incoerência que pudesse fragilizá-los. De se destacar que a narrativa segura e coesa apresentada pelos policiais na audiência judicial é idêntica àquela apresentada à Autoridade de Polícia Judiciária, circunstância que confere ainda mais credibilidade aos relatos.

Cumpra salientar que a condição de guarda civil e o fato de ter participado da ocorrência que culminou na prisão do acusado não tornam a testemunha suspeita ou impedida. Após regular compromisso, policiais merecem a normal credibilidade das testemunhas em geral.

Não se ignora que, com infeliz frequência, agentes públicos agem de forma abusiva e arbitrária. Porém, nada há nos autos que possa nos fazer duvidar da conduta dos guardas civis ouvidos, não havendo elementos que indiquem parcialidade ou intenção de prejudicar o réu, pessoa que sequer conheciam.

Como se não bastasse, a versão apresentada pelo réu de que é apenas usuário e que teria ido ao local para comprar drogas do adolescente se mostra inverossímil, visto que ambos teriam dispensado uma sacola e pochete quando perceberam a presença dos guardas civis, o que ratifica a sua participação no tráfico. Frise-se que, em sede policial, o adolescente confirmou que só estava portando a pochete.

Cabalmente demonstrado, portanto, o vínculo do réu com as drogas apreendidas.

A quantidade e variedade de entorpecentes (682 porções de drogas de três tipos), o dinheiro em espécie apreendido (R\$ 149,80) e contexto no qual desenvolvida a ação criminosa (abordagem em ponto de venda de drogas) não deixam dúvidas de que as drogas se destinavam ao tráfico. Assim, a conduta do réu se amolda ao tipo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Por fim, o delito foi praticado em concurso com o adolescente Jadyson, que na época dos fatos tinha apenas 17 anos de idade. Não bastasse as circunstâncias da prisão, que deixam clara a atuação em conjunto, o adolescente, em solo policial, confessou espontaneamente a traficância (fl. 16).

Nesse passo, provado que o réu praticou o crime do art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais do art. 59 do Estatuto Repressivo não são inteiramente favoráveis ao réu.

Não existem nos autos elementos que permitam valorar negativamente a sua personalidade. A culpabilidade não se mostra acentuada, revestindo-se apenas da reprovabilidade ínsita ao tipo penal. As circunstâncias, consequências e motivos do crime são absolutamente normais à espécie. Tratando-se de crime contra a saúde pública, não há comportamento vitimológico a ser analisado.

O acusado, no entanto, registra mau antecedente. Analisando a sua certidão criminal (fls. 30/32), constata-se a existência de duas condenações definitivas contra o réu. Nesta primeira etapa, valoro como mau antecedente a condenação sofrida pelo réu no processo nº 1502420-50.2020.8.26.0535, da 2ª Vara Criminal de Guarulhos, com trânsito em julgado em 30.07.2021 (fl. 103).

As circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 também não são favoráveis ao acusado. A quantidade de entorpecentes é considerável e há variedade de drogas.

Além disso, foi apreendida cocaína e lança-perfume, drogas de alta nocividade. Em razão dessas circunstâncias, fixo a básica acima do piso legal, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo, não há atenuantes.

Presente a agravante de reincidência, pois Carlos foi definitivamente condenado pelo crime de tráfico de drogas no processo nº 1502711-84.2019.8.26.0535, desta Vara Criminal, tendo a condenação transitado em julgado em 30.08.2021 (fl. 31). Em virtude dessa circunstância legal, majoro a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 07 (anos) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Diante da majorante majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas, aumento a pena em 1/6 (um sexto), o que resulta em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Não há minorantes. Não é possível a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que Carlos é reincidente específico.

Assim, torno definitiva a pena acima estabelecida.

Ao que consta, o acusado não goza de padrão de vida elevado. Diante da sua considerando sua presumível situação econômica, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época dos fatos.

Em razão da reincidência e quantidade de pena aplicada, Carlos deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime prisional fechado.

O tempo de prisão cautelar não autoriza a realização da detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

A quantidade de pena aplicada e a reincidência impedem a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Isto posto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o réu Carlos Vinicius Oliveira dos Santos, por violação ao art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 8 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no piso legal.

O réu não poderá recorrer em liberdade, pois seu histórico criminal indica que faz da prática de crimes seu meio de vida. Assim, há fundado receio de que Carlos volte a delinquir caso seja solto prematuramente. No mais, como ele respondeu ao processo preso, não se justificaria a soltura agora que condenado, especialmente diante do regime prisional imposto. Por estes motivos, mantenho a prisão cautelar. Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido.

Com fulcro no art. 63 da Lei nº 11.343/06, decreto a perda do valor monetário apreendido em favor do FUNAD.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei nº 11.608/03. Porém, tendo em vista sua parca situação financeira, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Com o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, com a devida comunicação ao IIRGD.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Cumpra-se.

Guarulhos, 30 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA